

1502032-18.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... traziam consigo, para fins de tráfico, 2 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 0,7g, e tinham em depósito, também para fins de tráfico, 12 (doze) porções de cocaína, com peso líquido de 4,1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que a central de monitoramento da Guarda Civil Municipal visualizou os acusados na via ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502032-18.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502032-18.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2353949/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 22197203

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ PAULO DE CAMPOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisela Ruffo

Vistos.

LUIZ PAULO DE CAMPOS e IVANILDO HENRIQUE DE SOUZA POMPEU, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. art. 29, "caput" do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 23h15, na Avenida Miguel Caparrós, 100, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba, agindo em concurso e identidade de propósitos, traziam consigo, para fins de tráfico, 2 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 0,7g, e tinham em depósito, também para fins de tráfico, 12 (doze) porções de cocaína, com peso líquido de 4,1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que a central de monitoramento da Guarda Civil Municipal visualizou os acusados na via pública em atitude típica de venda de drogas,

acionando os guardas municipais. Ao chegarem ao local apontado, os agentes identificaram IVANILDO, o qual entregava o entorpecente aos condutores dos veículos e, após receber o dinheiro, entregava a LUIZ PAULO, o qual escondia os valores nas imediações. Abordados, em revista pessoal, foram localizadas com IVANILDO duas porções de cocaína e R\$ 52,00 e, com LUIZ PAULO, a importância de R\$ 39,00. Vistoriado o local da abordagem foram localizadas mais seis porções de cocaína. Indagados informalmente, os réus admitiram a traficância, tendo LUIZ PAULO indicado o local onde havia mais seis porções de cocaína e R\$ 60,00.

Os réus foram notificados nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 262 e 264) e apresentaram defesa preliminar acompanhada de documentos (fls. 267/279), seguindo-se a decisão de fls. 285/288, que recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Designada audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e nove, pela Defesa. Após, os réus foram interrogados.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal dos réus.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, pela fotografia de fls. 18 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 353/355, que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, LUIZ PAULO confessou a prática delitiva. Disse que realmente traficava drogas no local dos fatos. Afirmou que os entorpecentes pertenciam a uma pessoa conhecida pelo apelido de Nenê, que deixava as substâncias no começo do turno e, no final, voltava para pegar o dinheiro. Asseverou que desconhecia maiores detalhes sobre esse indivíduo. Alegou que realiza o tráfico por necessidade financeira, em parceria com IVANILDO. Disse que receberia o valor de quarenta reais para traficar das 20h00 a 1h00 na data dos fatos (fls. 05/06).

IVANILDO, a seu turno, confessou parcialmente a prática delitiva. Disse que era usuário de drogas e sabia que o local era ponto de venda de drogas, lá permanecendo com a intenção de, eventualmente, ganhar alguma porção de cocaína. Afirmou que LUIZ lhe pediu para entregar dois pinos para um comprador que estava dirigindo um veículo, tendo ganhado uma porção para cheirar. Alegou que não era traficante, mas foi flagrado pelas câmeras justamente quando fazia a entrega das mencionadas porções (fls. 07/08).

Ouvido novamente, ainda perante a autoridade policial, LUIZ PAULO alterou sua versão. Afirmou: "estava num bar existente próximo ao local jogando bilhar. Disse que não conhece Ivanildo. Esclarece que tanto o declarante quanto Ivanildo estavam dentro do bar e foram abordados pelos Guardas no interior do estabelecimento. Relatou que os Guardas apresentaram as porções de drogas como sendo do declarante. Disse que foi colocado dentro da viatura, sem algemas. Inclusive, durante o percurso utilizou seu celular e avisou sua genitora para que comunicasse sua irmã, pois, os guardas estariam o levando até um pasto próximo da Rua Miguel Caparroz. No local, contou que foi retirado da viatura e os guardas o ameaçaram de morte, a fim de que assumisse as drogas, bem como lhe apontaram um revólver. Disse que Ivanildo ficou no interior da viatura. Declarou que por desespero assumiu a propriedade dos

entorpecentes. Esclarece que sua irmã, Daniele Cristina de Oliveira, chegou no local, mas já estavam saindo. Contou que antes de saírem do pasto, os guardas disseram que se o declarante não confessasse, iriam matá-lo assim que deixasse a Delegacia. Por fim, contou que não estava desempregado, pois, ajudava sua irmã Daniele numa loja de roupas e há quatro meses tinha sido dispensado da REMAQ, vivendo de seu fundo de garantia. Com relação as informações prestadas por ocasião de seu interrogatório, não procedem, sendo estas declarações a verdade dos fatos" (fls. 266).

Em juízo, os réus negaram a prática do crime.

LUIZ PAULO afirmou que estavam jogando bilhar no bar quando foram abordados pelos policiais. Disse que foi jogado na viatura e não entendeu nada. Asseverou que os guardas falaram que iriam levá-lo para um pasto, mas ficou com seu celular e mandou uma mensagem para sua mãe, para ela avisar sua irmã que mora perto. Alegou que, no pasto, os guardas apresentaram porções de drogas e começaram a agredi-lo, razão pela qual acabou admitindo uma coisa que não estava fazendo. Afirmou que, na Delegacia, ficou em silêncio. Sustentou que veio um monte de documentos para ele assinar e assinou sem ler. Disse que tinha chegado no bar entre 22h30 e 22h40, sendo que Ivanildo, que não conhecia, estava numa mesa, bebendo. Asseverou que foram abordados às 23h15 e não indicou que havia drogas no terreno. Alegou que não estava em poder de entorpecentes, só tinha R\$ 39,00. Disse que os guardas já tinham implicância com ele, já o haviam abordado e agredido. Informou que estava vivendo com o Fundo de Garantia e fazendo bicos na loja de roupas da sua irmã. Declarou que foi ouvido uma segunda vez pelo Delegado e falou que, no dia dos fatos, estava no bar e foi abordado e agredido pelos guardas. Disse que seu celular estava no bolso e entrou na viatura com ele, de modo que deu tempo de mandar a mensagem, posto que ainda não tinha sido agredido ainda, só foi agredido no pasto.

Ivanildo, por sua vez, disse que tinha dois pinos de cocaína em seu poder, pois é usuário, e foi ao local para tomar cerveja. Asseverou que chegou no bar às 23h00 e permaneceu ali para beber. Afirmou que, quando chegou, Luiz, que não conhecia anteriormente, já estava dentro do bar. Então, os guardas chegaram e os abordaram. Declarou que eles ficaram conversando com Luiz. Na sequência, foram colocados na viatura e levados para o mato. Informou que Luiz desceu com o guarda e não sabe o que aconteceu, pois permaneceu na viatura. Afirmou que eles saíram do mato com drogas, seis porções, e seguiram para a Delegacia. Disse que não se recordava do que falou na Delegacia. Atestou que não foi agredido, mas estava alcoolizado e drogado.

A confissão extrajudicial, entretanto, foi amparada pela prova produzida, não podendo ser desprezada.

A propósito do tema os seguintes julgados:

Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. (TJSP, 871392520098260050 SP 0087139-25.2009.8.26.0050, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 09/02/2012, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2012).

"HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM A CONVICÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, corroborada por depoimentos colhidos na fase instrutória. 2. Embora não se admita a prolação do édito condenatório com base em elementos de convicção exclusivamente colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se

verifica na hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal de origem apoiaram-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal. (...)" (STJ, 115255 MS 2008/0199821-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2010).

"Não se pode perder de vista que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E na espécie, não se vislumbram fatos que pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa confissão na polícia. De mais a mais, insista-se, a confissão naquela fase merece eficácia probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os testemunhos, tudo a permitir a responsabilização penal do recorrente. De mais a mais, a confissão policial pode prevalecer à retratação judicial, quando harmônica com o restante da prova, uma vez que aquela vale pelo grau de credibilidade que lhe seja inerente e não pelo local em que é colhida". (Revisão n.º 297.262/1, TACRIM, 4o Grupo de Câmaras, Relator: Luiz Ambra, RJTACRIM 35/497).

Vejamos.

O guarda municipal Joel relatou que estavam em patrulhamento quando a Central informou que o CEMEL tinha flagrado situação de possível tráfico de entorpecente no local. Atestou que, de posse das informações e das características dos agentes, foram ao local e abordaram os réus. Disse que, com um deles, o Ivanildo, encontraram duas porções de cocaína e dinheiro e, com Luiz, só dinheiro. Então, a central passou onde eles estariam ocultando os entorpecentes e, perto dos réus, encontraram mais seis porções de entorpecentes idênticos aos encontrados com Ivanildo. Atesou que a central informou que tinha observado que Ivanildo ia até os veículos, recebia algo e entregava algo aos condutores, depois passava o dinheiro ao Luiz. Esclareceu que, ao chegarem no local, já fizeram de imediato a abordagem dos réus. Narrou que eles foram questionados e disseram que estavam no tráfico. Então, Luiz falou que tinha escondido mais dinheiro no final da avenida. Declarou que os dois já estavam na viatura e seguiram ao local informado, onde tiraram o Luiz do veículo e ele indicou onde estava o dinheiro. Asseverou que o dinheiro estava embaixo de uma pedra e só acharam em razão da indicação do Luiz, pois era uma área de mata, com um pasto grande. Disse que fez varredura no local e ainda encontrou uma garrafinha com seis porções de cocaína. Acrescentou que já tinha abordados os dois acusados anteriormente, no mesmo local, já conhecido como ponto de tráfico. Informou que não houve qualquer agressão aos acusados e nem haveria possibilidade, pois a central estava acompanhando tudo. Observando a fotografia de fls. 382, afirmou que possivelmente é do final da avenida, onde, após a casa de portão branco, à esquerda, Luiz informou que estava guardado o dinheiro. Atestou que as filmagens ficam na posse da CEMEL.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Paulo. Acrescentou a testemunha que os réus foram informados de que o local era monitorado e eles tinham sido flagrados nas imagens, razão pela qual eles confessaram a prática do crime, pois nem tinha como negar. Declarou que a irmã do réu chegou quando estavam retornando do local onde encontraram o dinheiro e disse que tinha sido comunicada sobre a prisão, oportunidade em que falaram para ela se dirigir à Delegacia.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais

provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de guardas municipais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665).

Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Confira-se, sobre o tema, o seguinte julgado: “Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Alegação de ilegalidade da prisão realizada por Guardas Municipais. Atuação dos Guardas Municipais. Ausente ilegalidade – Artigo 301 do CPP – Qualquer pessoa do povo pode, e as Autoridades policiais e seus agentes devem realizar prisões em flagrante – Crime de Tráfico de Drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento. Jurisprudência do C. STJ. No caso em tela, ao que consta, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. No mais, eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva do Paciente. Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado. Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2014342-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

Não bastasse essa orientação já consolidada na jurisprudência, há que se ressaltar que, conquanto não seja essa essencialmente sua função, o guarda municipal está autorizado por norma legal expressa a encaminhar à presença da autoridade policial indivíduos presos em flagrante delito, consoante a regra inscrita no artigo 5º, inciso XIV, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

E o relato dos guardas foi corroborado pelas imagens captadas pelas câmeras do CEMEL.

Essas imagens, aliás, infirmam a assertiva que os réus apresentaram na fase judicial, no sentido de que estavam num bar e ali foram abordados pelos guardas, eis que ficou evidenciado que eles foram abordados quando estavam no canteiro central da avenida. As imagens revelam ainda que, antes do momento da abordagem, os réus estavam sentados num ponto de ônibus, do outro lado da rua, juntos, e realizaram atos típicos da traficância, atendendo pessoas que deles se aproximaram, com quem trocaram algo.

Consigno, para constar, que as imagens vieram aos autos antes do interrogatório dos réus, dando-se ciência à Defesa, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

De outro lado, as testemunhas arroladas pela Defesa não inocentaram os réus.

Allan disse que estava voltando do serviço, pois é entregador, e viu Luiz sendo abordado no canteiro central da avenida. Atestou que guardou sua moto em sua casa, que fica ao lado do bar e notou que Ivanildo estava sendo abordado também. Disse que não viu os policiais encontrando alguma coisa com os réus, nem dinheiro. Atestou que não viu os réus sendo agredidos pelos policiais. Disse que os réus foram colocados na viatura, que seguiu em direção ao pasto. Porém, não deu para ver o que aconteceu ali, pois o local já fica mais distante de sua casa. Asseverou que havia duas viaturas e ficaram perto do pasto durante aproximadamente vinte minutos. Aduziu que um amigo seu, chamado Leandro, falou que tinha visto Luiz anteriormente do bar, de onde ele foi retirado pelos guardas.

Bruna, namorada do corréu Luiz, falou que ele lhe telefonou quando estava na Delegacia, falando que iria ser preso e pedindo para ela ir até lá, onde a irmã dele já estava. Atestou que só teve contato pessoal com o réu após os fatos, nas visitas, e ele lhe falou que estava no bar, jogando bilhar, quando foram retirados pelos policiais e levados para um pasto. Afirmou que o réu não é usuário de entorpecentes e falou que não tinha drogas em poder dele, no dia dos fatos. Acrescentou que o réu lhe falou que os policiais o obrigaram a confessar, senão o matariam. Aduziu que, dias antes, o réu tinha sido abordado pelos mesmos policiais, que o ameaçaram, dizendo que ele não passaria a virada do ano solto. Disse que o réu já tinha sido internado na Fundação CASA, mas, depois que saiu, começou a trabalhar num lava-rápido, numa empresa de ar condicionado e na loja de roupas da irmã dele. Informou que a irmã do réu contou que foi ao local dos fatos e verificou que Ivanildo estava na viatura e Luiz no pasto, tendo os policiais falado que tinham uma gravação deles vendendo drogas, mas ficaram nervosos e não mostraram as drogas para elas.

Danielle, irmã do corréu Luiz, disse que sua mãe lhe telefonou, falando que Luiz mandou mensagem para ela dizendo que estava dentro da viatura e estava sendo levado para um mato pelos policiais, que iriam lhe "dar um pau". Afirmou que foi ao local, constatou que a viatura estava parada de ré, no pasto, e um dos policiais estava no pasto com seu irmão. Disse que um guarda estava na viatura, com outro indivíduo. Asseverou que esse guarda saiu da viatura e lhe falou que tinham flagrado o irmão dele traficando e tinha filmagem. Atestou que pediu para ver a filmagem e a droga, mas o guarda falou que só apresentava para o Delegado. Declarou que viu o outro guarda saindo do mato com seu irmão, mas esse guarda não falou com ela. Então, eles foram para a Delegacia e ela foi atrás. Disse que seu irmão não é usuário de drogas, que esteve internado na Fundação CASA e, quando saiu, passou a trabalhar. Atestou que ele trabalhava na sua loja de roupas e ganhava de R\$ 1.200,00 a R\$ 1.250,00. Aduziu que os guardas não lhe disseram porque foram para a mata, só falaram que iriam levar seu irmão para a Delegacia. Informou que não sabia quanto tempo os policiais ficaram com seu irmão na mata, mas, depois que ela chegou, passou pouco tempo, pois eles não sabiam o que fazer e foram todos para a Delegacia.

Ora, essas testemunhas não presenciaram o momento em que os réus foram abordados, nem os que o antecederam.

Allan afirmou que, quando chegou, os réus já estavam sendo abordados no canteiro central da avenida e um amigo lhe disse que Luiz tinha sido retirado do bar pelos guardas. Mas ele não presenciou o fato e, como já anotado, as imagens trazidas aos autos infirmaram essa tese.

Bruna e Danielle informaram que Luiz as comunicou de que fora detido, eis que manteve um telefone celular em seu poder, o que foi corroborado pelo documento de fls. 363, tendo Bruna se dirigido para a Delegacia e Danielle, para o local em que os guardas estavam com os réus. Porém, repita-se, não presenciaram o momento da abordagem e os que a antecederam.

É certo que Danielle declarou que, cientificada da detenção do irmão, o corréu Luiz, foi até o local dos fatos, vindo a encontrar a viatura da guarda, na qual estava o corréu Ivanildo, junto a um dos guardas, enquanto o outro guarda saía do pasto com seu irmão. Essa assertiva, porém, está em consonância com o relato dos guardas, que atestaram que seguiram para esse pasto, no final da via onde fizeram a abordagem, porque Luiz indicou que ali havia dinheiro, vindo a apreendê-lo no local apontado pelo acusado. Afirmaram ainda os guardas que a irmã do réu ali compareceu, sendo orientada a se dirigir até a Delegacia.

Por fim, as testemunhas Itamara, Nair, Nicole, Elaine, Kaique e Ana Paula nada esclareceram sobre os fatos, limitando-se a prestar informações sobre os antecedentes e a conduta social dos acusados.

Nesse contexto de rigor a condenação nos termos da denúncia.

Ora, os acusados foram flagrados pelas câmeras da central de monitoramento do município praticando atos típicos de tráfico e, na sequência, foram abordados por guardas municipais, que apreenderam entorpecentes em poder de Ivanildo e dinheiro em poder de Luiz, vindo ainda a encontrar mais porções de entorpecentes em local próximo a eles e em local por indicado por Luiz, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova. E os réus confessaram extrajudicialmente a prática da traficância, não apresentando justificativa plausível para a mudança de versão.

Impõe-se, portanto, a condenação dos réus como incursos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado IVANILDO ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).
2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que LUIZ PAULO é primário e não ostenta maus antecedentes. IVANILDO, a seu turno, ostenta maus antecedentes (autos 0037742-60.2006 da 1ª Vara Criminal local, 0057700-08.2001 da 2ª Vara Criminal local e 0057719-14.2001 da 3ª Vara Criminal local – conforme certidão de fls. 199/204 e informações da F.A da VEC à fls. 205/219).

De acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência, mas podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do mesmo código.

Nesse sentido decisão do C. STJ: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência mas podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. Considerando que o ordenamento jurídico pátrio adota quanto aos maus antecedentes o sistema da perpetuidade, e não da temporariedade, como no caso da reincidência, é de se manter o entendimento pacificado por este Sodalício de que, mesmo ultrapassado o prazo depurador, as condenações anteriores podem ser consideradas como maus antecedentes. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp nº 1.604.407/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12.08.2016).

E o STF, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Assim, com relação ao corréu LUIZ PAULO, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base no mínimo legal, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo, e, com relação a IVANILDO, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há circunstâncias agravantes. De outro lado, os réus confessaram extrajudicialmente a prática do delito. Logo, com relação a IVANILDO, reduzo a pena ao mínimo legal, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Quanto a LUIZ PAULO, porém, fixada a pena no mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la. A confissão espontânea, ainda que tenha sido externada apenas na fase extrajudicial, serviu de fundamento para a condenação. Logo, também deve ser considerada na segunda etapa de fixação da pena.

Nesse sentido, aliás, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RÉU QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA O DECRETO CONDENATÓRIO. HARMONIA DA CONFISSÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. (...) 2. A confissão extrajudicial retratada em Juízo constitui circunstância atenuante (alínea "d" do inciso III do art. 65 do CP), quando embasar a sentença penal condenatória. O que se deu no caso concreto. 3. Ordem concedida." (STF HC 91.654/PR 1ª T. Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 08.04.2008 DJU 07.11.2008).

Inexistem causas de aumento. E, não fazem jus os réus à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, IVANILDO ostenta maus antecedentes.

Já LUIZ PAULO ostenta passagem pela prática de infração equiparada ao tráfico de drogas, enquanto menor, com aplicação, inclusive, de medida socioeducativa de internação (autos 1500862-79.2019 da Vara da Infância e da Juventude, cf. certidão de fls. 222/226).

Esse fato, ainda que não enseje o aumento da pena, porquanto não pode ser considerado como maus antecedentes, não permite concluir que o réu seja traficante meramente ocasional, sem envolvimento com organizações criminosas e, portanto, merecedor da redução da pena.

Sobre o tema, já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Apelação nº 0000491-64.2016.8.26.0125, Rel. Des. Ivan Sartori, j. 23.06.17, no qual é invocado o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 quando demonstrado que a paciente

praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos 'servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza' e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada" (HC 121509/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 29.03.2010).

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar os réus LUIZ PAULO DE CAMPO e IVANILDO HENRIQUE DE SOUZA POMPEU, qualificados nos autos, à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, ambos como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29, "caput" do Código Penal, fixado o regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Piracicaba, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA